

1500911-54.2019.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/02/2022

... das drogas e anotações de contabilidade do tráfico.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recurso defensivo - Autoria e materialidade delitivas comprovadas - Prisão em flagrante e firmes depoimentos dos policiais militares - Desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 - Descabimento - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500911-54.2019.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500911-54.2019.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2250068/2019 - 02º D.P. LORENA, 7089940 - 02º D.P. LORENA, 1134/19/212 - 02º D.P.

LORENA, 2250068 - 02º D.P. LORENA, 1134/19/212 - 02º D.P. LORENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERICA MAIRA THEODORO DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de ÉRICA MAIRA THEODORO DOS SANTOS, qualificada nos autos, na qual lhe é atribuída a autoria do crime tipificado no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, em razão dos fatos narrados na exordial acusatória (fls. 95/96).

Oferecida a denúncia, a ré apresentou defesa preliminar (fls. 102/106). Não sendo caso de absolvição, a denúncia foi recebida em 18/10/2019, designando-se audiência virtual de instrução e julgamento, nos termos do artigo 56, da Lei 11.343/06 (fl. 111). Citação às fls. 170.

Em audiência foram ouvidas as testemunhas e as informantes judiciais. Ao final, o interrogatório foi realizado. Finda a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais, por meio de memoriais escritos.

O Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação da acusada, nos termos da denúncia (fls. 201/207).

Lado outro, a defesa pugnou pela improcedência da ação penal, com absolvição da acusada, por ausência ou insuficiência probatória. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/06; ou, caso condenada pelo tráfico, requereu a fixação da pena no mínimo legal, com o reconhecimento da figura privilegiada do tipo, com a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (fls. 211/221).

É O RELATÓRIO.  
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de exibição e apreensão (fls. 37/38), laudos de constatação provisória (fls. 33/36) e definitivo (fls. 86/88), detectada a presença da substância "cocaína", que se encontra descrita na Lista F1 (Lista das Substâncias Entorpecentes) da Lista F (Lista das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 143/2017 de 10/07/2017); bem como pelas provas orais contidas nos autos.

De igual modo, a prova de autoria é certa, recaindo sobre os ombros da acusada. A começar pelo estado flagrancial. Senão vejamos.

O investigador de polícia Maurílio Abreu Aquino, um dos responsáveis pela execução do mandado de busca e apreensão no endereço da acusada, contou que havia informações indicando que a ré ali realizava o tráfico de drogas, esclarecendo que no imóvel fronteiriço ao de Érica (nº 74), funcionava uma "biqueira" (ponto de venda de drogas). De acordo com o depoente, durante as buscas, a polícia encontrou, inicialmente, alguns pinos de "cocaína" no interior de seu guarda-roupa, ocasião em que a ré, a qual acompanhava a diligência, disse que seriam de uma amiga. Ainda durante as buscas foi achado um caderno com anotações sugestivas do vil comércio. Na sequência foi localizado, no forro do imóvel, um pote com diversos pinos de "cocaína", e nos fundos da parte externa da casa, já no terreno vizinho (casa abandonada), mais pinos plásticos, porém, vazios. Esclareceu que a genitora e os irmãos da acusada presenciaram as diligências. O policial contou que a ré, na ocasião, embora admitindo que já havia traficado no passado, disse que os entorpecentes encontrados não lhe pertenciam. Explicou que ninguém acompanhou as buscas no forro do imóvel, por ser um local de difícil acesso, e que do imóvel vizinho não era possível entrar naquele lugar, embora as casas fossem geminadas.

O outro policial civil, Robson Augusto do Nascimento, fez coro às suas palavras.

Andreia Hursula Theodoro, genitora da ré, contou que chegou ao local praticamente com os policiais, e os franqueou a entrada ao imóvel, após o mandado lhe ser exibido. Disse ter presenciado o momento em que três pinos de "cocaína" foram localizados, no quarto de sua filha. Narrou que os policiais foram à casa vizinha, abandonada, e depois de fazerem barulho, retornaram com mais drogas. Afirmou que os agentes da lei ameaçaram a ré, dizendo que, caso ela não assumisse a posse de todos os narcóticos encontrados, prenderiam a depoente e a ela, fato que fez com que Érica assim fizesse. A respeito do dinheiro apreendido na posse de sua filha,

afirmou que tal numerário seria utilizado para pagar o aluguel da casa, malgrado não tenha se recordado do nome do seu locador. A depoente disse estranhar as denúncias mencionadas pelos policiais envolvendo sua filha, contando que esta trabalhava com sua tia, irmã dela, à época. Esclareceu, por fim, que na garagem de sua casa, comercializava roupas usadas e biscoitos.

A testemunha Jenifer Paola de Campos contou que no dia dos fatos estava passando pela casa da increpada, e por isso, acabou presenciando a operação policial. Afirmou ter visto os policiais pegando objetos na casa abandonada, e após levando para a casa da acusada.

A irmã da acusada, Stefani Mayara Theodoro do Santos disse que acompanhou a diligência policial, por estar no imóvel. Disse, em linha com sua genitora, que os policiais vistoriaram a casa ao lado da ré. Questionada, contou que durante as buscas ficou na cozinha do imóvel com sua mãe, enquanto Érica permaneceu em seu quarto conversando com os agentes públicos. Relatou que dias antes dos fatos foi agredida por policiais militares (Amorim e Luciano), e que na oportunidade, sua irmã "tomou suas dores", discutindo com a dupla, a qual prometeu vingança. De acordo com Stefani, os policiais civis que cumpriram o mandado de busca domiciliar também tinham desavenças com Érica, pois estavam comungados os citados policiais militares.

Por sua vez, a ré negou o crime durante o ato destinado a sua autodefesa. Admitiu apenas a posse de três porções de "cocaína", argumentando que as consumiria. A interroganda afirmou que não acompanhou as diligências policiais, e que o restante da droga encontrada no telhado não lhe pertencia. Declarou que jamais realizou o vil comércio, e que apresentou aquela narrativa em sede policial, por estar muito nervosa e com medo de sua mãe ser acusada falsamente. Questionada, disse que o dinheiro apreendido serviria para quitar o aluguel da casa onde moravam, e que exploravam um bazar naquele local.

Eis a prova oral.

Como já sustentado em outras oportunidades, que aqueles que acompanham de perto as decisões deste Magistrado, bem sabem a credibilidade que costumo conferir às palavras dos policiais, sejam eles, militares, civis, federais, rodoviários federais, ou mesmo qualquer outro agente de segurança pública, seguindo, aliás, a maioria da jurisprudência dos nossos tribunais.

Confira-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça - STJ e do Tribunal de Justiça deste estado - TJSP:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido". (STJ; AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC; Relator: Ministro Ribeiro Dantas; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data da publicação: 23/03/2020); e

"Apelação criminal. Tráfico de entorpecente. Materialidade delitiva demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da substância entorpecente,

laudo de exame químico-toxicológico e prova oral. Autoria comprovada pela palavra de testemunhas policiais - Depoimentos insuspeitos e harmônicos, suficientes para alicerçar o decreto condenatório - Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos - (...) Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1514240-51.2019.8.26.0228; Relator: José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020) (Ênfase na reprodução).

E assim o faço, não só pela presunção de legitimidade que a própria lei confere aos atos por eles praticados, em razão da natureza pública da função que exercem, mas, também, por conta do total desinteresse deles em incriminar inocentes.

Afinal, como acreditar que policiais civis; cuja função precípua é impedir que a legislação penal seja inobservada nas ruas, ou nas estradas federais, caso, também, da polícia militar e da rodoviária federal, respectivamente, ou mesmo, investigar a autoria daqueles que a violaram, como é o caso da polícia civil e federal; vá, eles próprios, violá-la, com o fito de incriminarem um inocente? Não faz qualquer sentido!

E não é só! Há, ainda, mais uma razão para se atribuir grande importância à palavra de tais agentes públicos: na maior parte das vezes, eles são os únicos dispostos a testemunharem sobre o que realmente viram sobre determinado crime.

Por motivos óbvios, ressalvado as pessoas ligadas ao criminoso por vínculo de parentesco, como no caso destes autos; afinidade, ou mesmo amizade, poucas são as pessoas que se dispõem a testemunhar, seja em sede policial, ou mesmo em Juízo, a respeito de um determinado crime. E, infelizmente, é forçoso admitir que assim o fazem por um motivo justificável, ou, ao menos, compreensível: medo de represálias.

Decerto, conhecendo-se a triste realidade da violência urbana existente em um país pobre igual ao nosso, não é difícil imaginar o receio de um morador da periferia, onde também reside a maior parte dos traficantes e, por via de consequente, são instalados os pontos de venda de drogas nas cidades, se apresentar em sede policial e, depois, em Juízo, contar o que seu vizinho traficante faz em sua rua, por exemplo.

Nesta toada, negar a validade dos testemunhos de tais agentes de segurança implicaria negar vigência às leis penais. Na prática, estas restariam ineficazes.

Isso não significa, lado outro, de modo algum, que as palavras dos policiais e agentes públicos em geral tenham peso superior às demais. Pode-se dizer que, em se tratando de provas, não existe hierarquia entre elas, todas são relativas.

É a essência do sistema da persuasão racional, disposto no artigo 155, "caput", do Código de Processo Penal, adotado atualmente:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Outro não é o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

"Embargos de Declaração. Oposição contra acórdão. Prequestionamento. Violação ao artigo 156 do CPP em face do que dispõe o artigo 203 do mesmo código. Inocorrência. Alegação de que não constou no decisum o critério de avaliação da credibilidade dos depoimentos de testemunhas que teriam se retratado em juízo. Omissão não configurada. Valoração da prova de acordo com seu conteúdo, coerência e harmonização com os demais elementos constantes dos autos. Sistema da persuasão

racional ou do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP). Liberdade do juízo na ponderação das provas produzidas. Consideração dos elementos de convicção que se mostraram mais confiáveis e aptos a revelar a verdade dos fatos. Julgamento plenamente justificado. Embargos rejeitados". (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0005867-59.2002.8.26.0242; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Igarapava - Vara Única; Data do Julgamento: 10/11/2009; Data de Registro: 03/12/2009) (Sublinhado meu).

Destarte, fixada tal diretriz, observo que o caso, ora em apreço, é mais um daqueles em que o acionado tenta, em vão, desacreditar a fala dos agentes da lei, sem produzir sequer um início de prova do que alega.

Como se vê acima, apenas a genitora e a irmã de Érica sustentam que a maior parte das drogas foi localizada na casa vizinha, abandonada à época, ao contrário dos investigadores de polícia que disseram que os narcóticos foram encontrados no forro da residência onde moravam.

Saliente-se que o fato de as casas serem geminadas (conjugadas), em nada altera esse quadro, vez que, normalmente, ainda que seja único o telhado das edificações, a parede central que divide os imóveis, impede a comunicação entre ambos, tal como esclareceu o policial Maurílio.

Anote-se, outrossim, que o depoimento da testemunha Jenifer não abala a narrativa acusatória, na medida em que os policiais confirmaram que os pinos plásticos, do tipo "eppendorf" vazios foram localizados e apreendidos na casa vizinha.

Todavia, repiso: tal circunstância não afasta a certeza da responsabilidade da acusada pelas drogas localizadas no forro de sua casa, já que também apreendidos dentro do seu guarda-roupa mais entorpecentes, anotações sugestivas do vil comércio, e dinheiro. Além disso, não se perca de vista que a ré já era anteriormente investigada por suspeitas de realizar a mercancia em seu endereço, tanto é que este Juízo deferiu a expedição de mandado de busca domiciliar em seu desfavor.

E não é só. Ao contrário das testemunhas policiais, as quais mantiveram a mesma versão desde a fase policial, a ré e sua genitora apresentaram enredos diversos ao longo da persecução criminal.

Decerto, perante à autoridade policial, Andreia (mãe da acusada), admitiu que as drogas foram encontradas no telhado de sua casa, bem como outros ilícitos, no quarto da increpada (fl. 07).

Já a acusada, por sua vez, frise-se: acompanhada de advogado naquela ocasião; reconheceu o exercício do vil comércio anterior, embora negando a propriedade/posse dos narcóticos encontrados pela polícia.

Esclareça-se que é desnecessário para a tipificação do crime de tráfico de drogas o agente ser flagrado em atos de mercancia, em que pese as abundantes informações que, realmente, a ré traficava naquele local, visto que presente uma dentre as múltiplas ações previstas no tipo penal, a finalidade mercantil deve estar demonstrada pelas circunstâncias do caso, como quantidade das drogas e anotações de contabilidade do tráfico.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recurso defensivo - Autoria e materialidade delitivas comprovadas - Prisão em flagrante e firmes depoimentos dos policiais militares - Desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 - Descabimento - Tipo penal que prevê diversas condutas -

Desnecessidade da prova da efetiva mercancia - Condenação mantida - (...) Recurso não provido". (TJSP; Apelação Criminal 1500932-98.2019.8.26.0566; Relator: Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019) (Ênfase na reprodução).

Ademais, a despeito de se declarar usuária de drogas, essa eventual condição de Érica, de modo algum, afasta a tipicidade de sua conduta pelo artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Ora, como é de notório conhecimento, não raro usuários passam a vender drogas com o fim de financiar a própria dependência e, nos presentes autos, a quantidade dos entorpecentes apreendidos excedem a de um simples usuário, principalmente, porque, neste caso, foram apreendidos anotações e dinheiro, não se podendo falar em desclassificação para o artigo 28, da mesma Lei.

Seguem julgados com o mesmo entendimento:

"Apelações criminais. (...) Não há possibilidade de se desclassificar as condutas para mero porte de drogas, certo que a jurisprudência não descarta a figura do usuário/traficante. 2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o tráfico aos apelantes e apelado (...) 6-) Recursos presos". (TJSP; Apelação Criminal 0001106-76.2017.8.26.0559; Relator: Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 05/12/2019; Data de Registro: 06/12/2019); e

"Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, caput, e § 4º da Lei 11.343/06 (...) Condição de usuário não tem o condão de descaracterizar o crime do artigo 33 da referida norma, a qual possui conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, sendo o bastante para a sua caracterização a prática de apenas uma delas (...) Dado parcial provimento ao recurso". (TJSP; Apelação Criminal 0002190-02.2017.8.26.0628; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 02/12/2019) (Sublinhados meus).

Por fim, saliente-se que o alegado "complô" dos policiais para prejudicar Érica, tal como sustentou sua irmã não foi minimamente comprovado, deixando a defesa de se desincumbir do ônus que sobre ela recaía, na forma do artigo 156, caput, do Código de Processo Penal.

A propósito:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO (MACONHA, COCAÍNA E CRACK) - OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA, ABRANDAMENTO DO REGIME E DETRAÇÃO PENAL - IMPOSSÍVEL ATENDER AOS PLEITOS - PRISÃO EM FLAGRANTE EM PONTO DE VENDA E NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS - NEGATIVA DO RÉU ISOLADA E ACUSAÇÃO DE EXTORSÃO RECHAÇADAS PELAS DEMAIS PROVAS, EM ESPECIAL DIANTE DOS DEPOIMENTOS SEGUROS E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE - O ÔNUS DA PROVA QUANTO AO ÁLIBI É DO RÉU, NOS TERMOS DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONDENAÇÃO BEM LANÇADA - A PENA FOI FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADOS TODOS OS ACRÉSCIMOS - A QUANTIDADE DE PENA E A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA JUSTIFICAM O REGIME FECHADO - RECURSO DESPROVIDO". (TJSP; Apelação Criminal 0001394-33.2016.8.26.0535; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/04/2020; Data de Registro: 16/04/2020) (Ênfase na reprodução).

Portanto, as circunstâncias fáticas acima apontadas não deixam qualquer dúvida, seja a respeito tanto da posse/propriedade dos narcóticos apreendidos pela acusada, ou mesmo da finalidade mercantil destes. Assim, o caso é de condenação, nos termos da denúncia.

Passo à modulação penal.

A ré é primária e de bons antecedentes.

Contudo, tenho que a conduta de Érica merece maior reprovação, à luz da quantidade de droga apreendida (23,06 gramas de "cocaina", peso líquido, divididos em 45 pinos plásticos, do tipo "eppendorf", prontos para a venda), a fim de diferenciá-la de outra envolvendo menor quantidade.

Anote-se, outrossim, que foi apreendido valor em dinheiro trocado (R\$ 500,00), circunstância a indicar que o tráfico já lhe havia dado lucros (veja-se que a ré não comprovou a origem lícita desse valor).

Assim, considerando tais circunstâncias, estabeleço a basilar em 1/8 (um oitavo) do mínimo legal, ou seja, em 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa, tornada aqui definitiva, à míngua de outras circunstâncias modificadoras das penas.

A acusada não faz jus à redutora prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, uma vez que as circunstâncias do caso concreto denotam sua profunda intimidade com o narcotráfico, evidenciando sua dedicação às atividades criminosas, a despeito de tratar-se de primária e de bons antecedentes, aos olhos da lei.

Ademais, não se perca de vista que a acusada já era investigada pela prática do comércio maligno, tanto é que sua prisão em flagrante ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido por este Juízo (autos em apenso nº 1501405-37.2019.8.26.0323). Aliás, durante a referida diligência, os investigadores de polícia encontraram um caderno contendo anotações sugestivas do tráfico de drogas, o que apenas faz reforçar a conclusão acima.

Como se não bastasse, esclareço que Érica responde atualmente a outra ação penal, em trâmite nesta Vara Criminal (autos nº 1500178-88.2019.8.26.0621), tudo a indicar sua dedicação perene à prática de atividades ilícitas.

A propósito, informativo desse mesmo Tribunal Superior, nesse sentido:

"É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06" (Informativo nº 0596, Publicação: 1º de março de 2017; STJ; EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, por maioria, julgado em 14/12/2016, DJe 1/2/2017).

Veja-se que tais elementos, indicam claramente que a increpada é pessoa que se dedica às atividades criminosas, situação que afasta a incidência dessa causa de diminuição de pena, visto que não existe prova direta dessa circunstância, "os criminosos não circulam com uma 'carteira de identificação de pessoa dedicada a atividades criminosas'", como bem lançado pelo Ministro Luiz Fux, do C. Supremo Tribunal Federal, em julgado que assim se encontra a ementa:

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções hominis ou facti, pelo juiz, para decidir sobre a procedência do ius puniendi, máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como "a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias". Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa

Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 2. O julgador pode, através de um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, mediante raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 3. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitativa. 4. (...) 5. In casu: (i) consta dos autos que o paciente, em concurso com um adolescente, transportava e tinha em depósito, para consumo de terceiros, 6,280 Kg (seis quilos e duzentos e oitenta gramas) de maconha, e 787,9 gramas de cocaína em pedra, acondicionadas em invólucros, disso resultando sua condenação a 5 (cinco) anos de reclusão e a 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, por estar incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; (ii) para fundamentar a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o Juízo de origem ponderou negativamente as circunstâncias do crime, destacando a forma como a droga estava acondicionada e o concurso de pessoas, com envolvimento de adolescente, de forma a facilitar a comercialização, tudo conduzindo à conclusão de que não se trata de uma ação individual e ocasional, mas sim que o paciente se dedicava a atividades criminosas; (iii) apesar da robusta fundamentação, sustenta o impetrante que não houve adequada motivação do arredamento da aludida minorante, pois entende que teria sido considerada apenas a quantidade da droga. 6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectual irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. Ordem denegada. (STF; HC 101.519/SP; Relator: Min. Luiz Fux; Órgão Julgador: 1ª Turma; Data do julgamento: 20/03/2012; Data da publicação: 26/04/2012).

Destarte, dado que essa causa de redução da pena é destinada àquele que age por um impulso, em situação isolada no tráfico de drogas, incidindo na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida da acusada, não é o caso destes autos.

Com relação ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, anote-se que o delito de tráfico é equiparado aos crimes hediondos, de acordo com a atual redação do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 e, por isso, não se mostra razoável a incidência do regime aberto ou semiaberto para o cumprimento da reprimenda, em que pese não seja obrigatório o regime mais gravoso, devido ao C. Supremo Tribunal Federal – STF ter reconhecido, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do parágrafo citado (HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli).

Porém, convém lembrar, na esteira do julgado citado da Suprema Corte, que isso não invalida a discricionariedade judicial, com possibilidade na análise do caso concreto, de fixação do regime fechado quando entendido como sendo o mais adequado.

No caso dos autos, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, à vista das circunstâncias judiciais desfavoráveis, forte no artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Veja-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. (...) Impossível aplicar o redutor, diante das peculiaridades concretas do caso. Quantidade e diversidade de entorpecentes denota envolvimento perene do réu em atividade de tráfico estruturada. Regime fechado adequado à hipótese em comento. Impossibilidade



de substituição por restritiva de direitos. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso improvido". (TJSP; Apelação Criminal 0007020-71.2018.8.26.0047; Relator: Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 14/11/2019; Data de Registro: 14/02/2020) (Ênfase nas reproduções).

Ademais, em se tratando de tráfico de drogas, distinto da figura privilegiada, estabelecer regime inicial diverso do fechado acabaria por também por ofender todo o arcabouço legal relativo à prevenção e reprovação do tráfico de drogas, já que a Constituição Federal, nossa lei maior, em seu artigo 5º, incisos XLIII e LI, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, autorizando até mesmo a extradição de brasileiro naturalizado, de forma a harmonizar a legislação pátria aos tratados internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário, não havendo razão para que, neste caso concreto, não dê cumprimento as essas políticas-criminas assumidas.

Por fim, fixo o dia-multa no piso legal, com base no salário-mínimo na data dos fatos, atualizado até o momento do seu efetivo pagamento, por serem parcas as informações acerca da situação financeira da acusada, forte no artigo 43, da Lei 11.343/06.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar ÉRICA MAIRA THEODORO DOS SANTOS, qualificada nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, a uma pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado; bem como ao pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, diária mínima, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com valor total da pena de multa a ser atualizado nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Incabível, a aplicação de medidas despenalizadoras, em razão do montante de pena aplicado.

Concedo-lhe, no entanto, o recurso em liberdade, considerando a decisão de fls. 143/149, e a inexistência da alteração do quadro fático, desde então.

Custas pela vencida.

Encaminhem-se as drogas apreendidas, oficiando-se à autoridade policial para proceder à sua destruição, expedindo-se o necessário.

Decreto o perdimento da quantia apreendida, em favor da União, ante as evidências de ser originária do vil comércio, conforme acima exaustivamente fundamentado, com fulcro no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. Expeça-se o necessário, com o trânsito em julgado.

A propósito:

"APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS – Preliminar – Restituição de valor apreendido – Desacolhimento – Caderno processual que indica que o numerário questionado é proveniente da prática do tráfico de drogas – Inexistência de prova segura acerca da origem lícita do dinheiro apreendido – Perda em favor da união corretamente determinada – Inteligência dos arts. 62 e 63 da Lei n.º 11.343/06 – Preliminar rejeitada. (...) Condenação mantida. (...) – Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1500220-88.2021.8.26.0356; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mirandópolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/11/2021; Data de Registro: 08/11/2021) (Ênfase minha).

Oportunamente, também após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeçam-se mandado de prisão, e, com a sua captura, a guia de execução definitiva; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste

Estado, comunicando a condenação da ré, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, § 2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; d) Oficie-se a autoridade policial nos termos do artigo 72, da Lei 11.434/06, sobre a amostra guardada para contraprova; e e) Adotadas as cautelas legais, com o cadastramento dos processos de execução, arquivem-se com baixa.

P.I.C

Lorena, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA